

SW특허는 기술혁신을 이끄는가?

김 윤 명

(소프트웨어정책연구소 선임연구원, 법학박사)

【초 록】

특허제도는 특허의 발명, 이용, 보호라는 세 가지 축의 균형을 통해서 그 목적을 달성할 수 있다. 지금까지는 보호를 중심으로 이루어져왔다고 해도 과언이 아니다. 소프트웨어 특허도 활용을 목적으로 하기보다는 경쟁업자의 침해를 차단하기 위한 목적으로 이루어지고 있다. 따라서 특허는 활용성은 떨어지고, 기술진보나 혁신을 목적으로 하는 특허제도의 취지와는 괴리가 발생하게 된다. 따라서 방어적 특허보다는 이용을 통해서 기술발전이나 문화창달에 기여할 수 있도록 해야 한다. 저작권 제도와 특허제도의 가장 큰 차이점 또는 소프트웨어 특허의 가장 큰 문제점은 타인의 특허를 모방하지 않아도 특허권 침해가 된다는 점이다. 이러한 이유로 특허가 기술개발을 유인하는 것인지 의문이 제기된다. 따라서 기술혁신을 이끌어내기 위한 특허전략은 “기술 보호가 아닌 기술 이용”으로 정책적 방향을 수립하는 것이 필요하다고 보았다.

주제어 : 저작권 제도, 특허제도, 소프트웨어, 소프트웨어 특허, 기술혁신

【차 례】

- | | |
|----------------------|----------------------|
| I. 서론 | 4. 소결론 |
| II. SW의 보호와 특허제도 | IV. SW특허와 기술혁신의 관계 |
| 1. SW의 보호 방법 | 1. 기술혁신을 위한 선택 |
| 2. 특허법의 목적과 기술혁신 | 2. SW특허에 대한 저작권법적 고찰 |
| III. 특허대상으로서 SW 발명 | 3. SW의 기술혁신에 대한 우려 |
| 1. SW 발명 | 4. SW특허와 기술혁신과의 상관성 |
| 2. 특허에 의한 SW보호 논의 | V. 결론 |
| 3. SW의 인터넷 유통과 특허 실시 | |

I. 서론

기술혁신이나 진보는 신기술의 개발을 통해서도 가능하지만, 이미 누군가에 의해 개발된 기술을 보다 개선시킴으로써도 가능하다.¹⁾ 소프트웨어(software, 이하 ‘SW’라 함)도 다르지 않으며, SW가 일상적으로 사용되는 요즘 SW의 가치는 HW의 가치를 넘어서고 있다. SW기업인 오라클(Oracle)이 HW기업인 썬(SUN)을 흡수한 바 있으며,²⁾ “자동차는 기름이 아닌 SW로 간다”라는 말을 벤츠의 CEO가 갈파하기도 하였다.³⁾ 이처럼 우리는 SW는 HW 이상의 가치를 갖게 된 ‘SW중심사회’⁴⁾에 위치하고 있다.

물론 SW가 독립된 가치를 가지게 된 것은 시장의 자발적 요구라기 보다는 IBM이 HW 시장에서 갖는 독점적 지위에 대한 독점금지법의 효력 때문이었다.⁵⁾ 이후 SW는 독자적인

1) 뉴튼은 “거인의 어깨위에서 멀리 본다”라는 말로 기술혁신은 이미 누군가의 기술을 바탕으로 한다는 점을 지적한 바 있다. 17세기의 통찰이 그러할진데, 21세기에는 더욱 선행기술을 바탕으로 하는 계량발명이 차지하는 규모가 작지 않다는 점에서 이러한 통찰은 여전히 유효하다고 생각된다. Suzanne Scotchmer, Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law, Journal of Economic Perspectives, Vol.5, No.1, 1991, p.29.

2) 재미있는 것은 썬마이크로시스템즈가 오라클에 인수되면서, JAVA API를 구글이 임의 사용한 것에 대해 오라클이 구글을 상대로 저작권 및 특허권 침해 소송을 제기하였다는 점이다. 1심, 항소심을 거쳤고, 1심에서는 구글을 항소심에서는 오라클의 입장이 인용되었다.

3) 다임러 AG 이사회 의장이며 메르세데스-벤츠 자동차그룹의 대표인 디터 제체 회장이 세계 최대 가전전시회 ‘CES 2014’에서 언급한 말이다. 실제 자동차의 R&D 중, SW가 차지하는 비중이 50%를 상회한다고 한다.

4) SW중심사회란 SW가 개인, 기업, 정부 전반에 광범위하게 사용되어 삶의 질을 향상시키고, 기업과 정부의 경쟁력이 지속적으로 제고되는 사회를 말하며, 인간중심의 사회를 의미한다. 소프트웨어정책연구소, SW중심사회 : 의미와 대응방향, 이슈리포트 2014-003, 2014, 6면.

5) SW가 지금과 같은 성장을 하게 된 것은 IBM의 분리정책이었다. 즉, “SW는 단순하고 경제적 가치

가치체계로서 발전해왔고, 그 과정에 MS, 오라클, SAP, 한글과컴퓨터 등 많은 SW 사업자들이 시장을 개척해왔다. 지금은 네이버, 구글, 알리바바 등 SW플랫폼사업자가 인터넷을 지배하고 있으며, 이 모든 것이 SW로서 가능하게 되었다. 또한 스마트폰이나 웨어러블 컴퓨팅 등 SW는 이미 우리 일상에 스며들어 굳이 다른 것과 구분할 수 없을 정도로 체화되고 있다. SW는 HW의 변들이 아닌 HW의 가치를 높여주는 가치체로서 역할을 하는 수준이다. 즉, SW는 단순한 기능을 수행하는 것이 아닌, 인간의 중심에 있으며 인간을 위한 역할을 하고 있는 것이다.⁶⁾

이처럼 일상의 요소를 구성하는 SW의 보호방법은 특허, 영업비밀 및 저작권 등 여러 가지가 있다. 그렇지만 어떤 방법이 개발자나 사업자에게 효과적인지는 판단하기가 쉽지 않다. 제도적 특성으로 동일한 대상이 다양한 방법에 따라 보호방법을 달리하는 것이 개발자에게는 혼동을 줄 수도 있으나, 지금까지 SW의 보호방법은 컴퓨터프로그램으로서 보호방법이 선호되었다. 왜냐하면, 저작권법은 창작과 동시에 별도의 절차 없이 권리가 발생하기 때문이다. 특허와 달리 권리 취득에 필요한 비용이 발생하지 않는 것도 하나의 요인이다.

글로벌(global) 기업들의 특허분쟁이 확대되면서 특허에 대한 관심이 커지고 있다. 삼성전자와 애플의 특허 분쟁, 오라클과 구글의 API, 비즈니스모델 특허의 무효소송, NPE의 특허 침해 소송 등 작지 않은 SW 관련 분쟁이 발생하면서 SW에 대한 법적 보호의 관심이 커지고 있다.⁷⁾

저작권 제도와 특허제도의 가장 큰 차이점 또는 SW 특허의 가장 큰 문제점은 타인의 특허를 모방하지 않아도 특허권 침해가 된다는 점이다. 이러한 이유로 특허가 기술개발을 유인하는 것인지 의문을 갖게 된다. 또한 제품의 수명주기가 4~12개월인 SW에 있어서 특허보호가 의미가 있는지에 대해 논란이 있다.⁸⁾ 이와 더불어, SW특허에 대한 논의에 있어

가 적었으므로 별로 중요시하지 않았다. 또 HW 가격이 고가이었으므로 SW는 HW에 수반되어 제공되는 서비스정도로 생각되었다. 그러나 SW에 관한 기술이 발전하고 경제적 가치가 현저해지면서 이것들이 분리되기 시작했다. 1969년 IBM이 가격분리정책(unbundling)을 채택, SW에 별도의 가격을 매기기 시작하면서 독립된 상품으로써 인식되었다”고 한다. 이상정, 컴퓨터프로그램보호법의 제정 경위와 우리의 현실, 한국지적재산권학회, 4면; Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, Library of Congress, 1979, p.24.

6) 포털, 플랫폼, 이메일, 메시징 등 모든 삶의 영역에서 수시로 사용되는 것이 바로 SW를 통한 컴퓨팅이다. 더욱이 이제는 자동차, 가전, 시계 등 모든 생활 영역에서 SW는 그 기능을 확대하고 있다.
7) 물론 SW 분야에서 게임이 차지하는 비중도 작지 않다. 기본적으로 게임물을 구성하는 매킨리즘은 SW를 기반으로 하기 때문에 게임물의 보호방식을 어떻게 선택할 것인지는 작지 않는 문제이다. 이러한 점에서 게임SW에 대한 법적 보호 방식 중 특허방식이 어떠한 의미를 갖는지에 대한 검토는 의의가 있다.

8) Melissa A. Schilling, 김길선 역, 기술경역과 혁신전략, McGraw-Hill Korea, 2011, 2면.

서 중요한 것은 SW특허가 기술발전과 혁신에 미치는 영향 및 그로 인하여 미칠 수 있는 소비자 후생에 관한 내용이다. 또한 SW의 실시 없이 NPEs에 의한 소송의 수단으로써 활용되는 경우에는 기술혁신이나 발전에 기여한 것으로 보기 어렵다. 이러한 점에 근거하여, 본 연구는 기술혁신을 이끌어내기 위한 특허전략은 “기술 보호가 아닌 기술 이용”으로 정책적 방향을 수립하는 것이 타당하다고 보았다.

II. SW의 보호와 특허제도

1. SW의 보호 방법

가. SW의 특성

SW 관련 기술은 일반적으로 “누적적, 연속적으로 발전하는 특성을 지니고 있고, 새로운 요소, 기존의 요소 등을 변형 또는 재사용하는 것이 빈번하며, 프로그램, 시스템, 네트워크 요소들 간의 상호운용성을 유지해야 하기 때문에 후속개발자의 기술혁신이 제한되는 등의 특성이 있다”⁹⁾고 한다. 또한 특허로 보호받기 위해서는 진보성을 갖추고 있어야 하는데 현대 컴퓨터프로그램의 기술혁신은 누적적, 연속적, 점증적이라는 특성을 가지고 있다. 그래서 컴퓨터프로그램은 특허요건으로서의 진보성 요건을 충족시키기 어렵다. 더욱이 특허로써 보호한다고 하더라도 특허권은 배타적 권리이기 때문에 누적적 연속적으로 발전하는 컴퓨터프로그램의 발전과정에 홀드업, 로열티스토킹 등의 현상을 유발하여 컴퓨터프로그램의 발전을 오히려 정체시킬 우려가 있다고 지적된다.¹⁰⁾

나. SW의 보호

SW의 성격은 다양하다. 우선 SW는 컴퓨터프로그램저작물로서의 성질을 갖기도 하다. 소스코드 자체 및 설계서 등은 어문저작물로서 성질을 갖는다. 물론 특허법에서는 SW 특허로서 성질을 갖기도 하다.¹¹⁾ 앱(app)으로 넘어갈 경우에는 SW는 콘텐츠와 동일성을 갖는다. 더욱이 인터넷 플랫폼이나 SW 플랫폼의 경우에는 서비스와 SW가 동일하게 기능하

9) 김기영, 소프트웨어 특허 침해에 대한 구제, LAW&TECHNOLOGY 제3권 제4호, 2007.7, 66면.

10) 구대환, 컴퓨터프로그램 기술혁신의 효과적인 보호를 위한 제언, 창작과권리, 2011, 166-167면.

11) Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 192(1981).

기 때문에 이를 구분하는 것도 쉽지 않다.

기본적으로 수학적 알고리즘이나 사업방법은 추상적 아이디어이기 때문에 특허권을 부여하더라도 특허 청구범위가 불명확해지거나 지나치게 광범위하게 되어 관련 분야의 과학 기술의 발전을 오히려 저해한다고 이해됐다. 그러나 기술의 발전은 이러한 내용을 반복적으로 생산할 수 있도록 함으로써 추상적 아이디어의 수준을 넘어서 구체적인 기술적 사상에 속하는 경우가 증가하게 된다.¹²⁾ 결국 컴퓨터의 성능과 SW의 발전에 따라 SW특허에 대한 구체적인 구현가능성이 높아지기 때문에 특허가능성도 높아짐을 알 수 있다.

2. 특허법의 목적과 기술혁신

가. 특허법의 목적

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 특허법의 목적은 특허를 보호하는 것이 아닌 발명을 보호하고 장려하는 것이다. 즉, 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말하는 발명을 보호하고 장려하는 것을 목적으로 한다. 특허법의 또 다른 목적은 발명의 이용을 도모한다는 것이다. 창작된 발명을 이용하여 제3자가 계량하여 또 다른 발명을 만들 수 있는 바탕이 되거나, 창작된 발명을 기술사업화하는 것을 의미하기도 한다.

특허법의 목적은 여기에만 머무르지 아니한다. 발명의 보호·장려·이용을 통해서 기술축진을 이끌어낸다는 것이 또 하나의 목적이다. 발명이라는 기술적 사상이 창작되는 과정을 거치면서 보다 진보한 기술이 개발될 수 있기 때문이다. 발명은 이용하는 과정에서 기술의 혁신을 이끌어내는 역할을 한다.¹³⁾ 물론 기술의 진보나 혁신 자체가 아닌 그 진보를 통해서 만들어진 기술은 관련 산업을 발전시키게 된다. 결국 보호 및 장려를 통해서 만들어진 발명을 이용함으로써 기술의 혁신을 가져오고 결과적으로 산업은 발전하며, 국민경제에 기여하게 된다는 것이 궁극적인 특허법의 목적이다.¹⁴⁾ 이러한 공공의 이익을 위하여 발명에 대해 독점권을 부여하고, 대신 해당 기술을 공개하고 실시하도록 의무를 부여하는 것이 특

12) 정상조·박준석, 지식재산권법, 홍문사, 2013, 56-57면.

13) “특허발명의 강제실시에 관한 규정도 연구시험의 예외와 마찬가지로 특허법의 목적에 해당되는 발명의 이용 및 기술발전의 촉진을 효율적으로 달성하기 위해서 필연적으로 요구되는 제도적 장치”라고 한다. 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 20면.

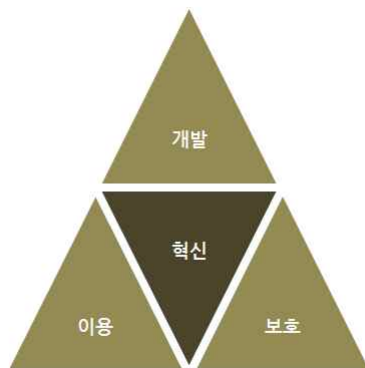
14) “특허법의 범목적은 발명과 경쟁이 모순충돌의 관계에만 있는 것이 아니라 상호보완할 수 있다는 전제로 하고있다는 것”이라고 한다. 손경한 편저, 신�특허법론, 법영사, 2005, 41면.

허제도의 취지이다.¹⁵⁾ 많은 사람들이 특허법이 특허만을 보호한다는 것으로 오해하고 있으나, 이는 특허제도를 운영하는 과정에서 정책의 형평을 맞추지 못한 점에서 기인한 것이 아닌지 생각된다.¹⁶⁾ 향후, 특허 및 저작권을 포함한 지식재산권 정책에서는 보호는 물론 이용을 통해서 궁극적으로 문화나 산업의 발전을 이끌 수 있어야 할 것이다.

나. 기술혁신

특허법의 목적은 발명의 장려를 통해서, 기술축진을 이끌어내는 것이다. 기술혁신이나 축진을 통해 국민경제의 발전이라는 궁극적인 제도적 취지를 달성하게 된다. 다만, 기술혁신이나 축진이 갖는 의미는 다양하다.¹⁷⁾ 단순한 개선이 이루어진 경우라도 그 가치가 높은 경우도 있지만, 수많은 자본이 투입된 경우라도 그 가치를 인정받기 어려운 경우도 있기 때문이다. 결국 가치판단은 시장에서 이루어질 수밖에 없다. 그렇기 때문에 특허제도는 기술의 혁신을 가져오는가라는 본질적인 의문은 여전히 해소되지 않는다.

<그림1> 기술혁신을 위한 3가지 축¹⁸⁾



15) 이러한 측면에서 “특허란 일정한 요건을 만족하는 발명을 공중에게 공개하는 대가로 일정한 기간 동안 독점, 배타적 권리를 부여받는 국가와의 공적 계약”이라고 한다. 조영선, 특허법, 박영사, 2011, 1면.

16) 참고로, 저작권법은 저작권 및 인접한 권리의 보호 및 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 발전을 목적으로 한다. 많은 사람이 오해하고 있는 것처럼, 저작권법은 저작권자만을 위한 법이 아니다. 이런 오해를 해소하기 위해서는 저작권의 보호 및 이용을 통해서 문화 및 산업의 발전을 이끌어냄을 목적으로 한다는 점을 이해할 필요가 있다. 이런 점에서 특허법의 목적도 저작권법과 다르지 않음을 알게 된다.

17) 독점은 상대 기업의 시장진출을 차단하여 기술혁신을 저해하고 스스로도 경쟁이 요인을 사라지게 함으로써 기술혁신의 악순환을 가져올 수 있다. 물론 상대 기업도 기술혁신을 통해서 독점기업을 넘어설 가능성도 있겠지만, 현실적인 재원이 소요되는 기술개발에서 쉽지 않다고 본다.

18) 특허는 개발, 보호 및 이용의 선순환 구조를 통해서 기술혁신을 이끌어낼 수 있다. 만약 어느 하나가 제대로 작동하지 못한다면 기술의 혁신이 가능하다고 보기 어렵다.

기술혁신은 다양한 기술의 공개를 통해서 아이디어를 얻고, 그 아이디어를 개량함으로써 보다 진보한 기술을 개발할 때 일어난다. 기술은 기존에 없던 것이 아닌 기존에 존재한 기술을 개량함으로써 기술적 진보가 일어난다. 그렇기 때문에 기술을 독점화할 경우에는 공유·공개를 통해서 형성되고 있는 공유경제(collaboration economy)에도 부정적인 영향을 끼칠 수 있다.

우리 특허법은 제1조 목적규정에서 발명의 장려와 이용을 통해서 기술의 발전을 이끈다고 규정하고 있다. 즉, 발명의 장려나 보호만이 아닌 이용을 통해서 기술의 발전을 이끌어낼 수 있다는 명제를 선언하고 있다. 물론 특허 출원된 기술사상은 공개되기 때문에 누구라도 참조할 수 있다. 그렇기 때문에 발명을 장려하고, 특허출원토록 함으로써 기술사상을 외부에 공개하고, 해당 기술의 존재여부를 확인함으로써 중복개발의 문제를 해소할 수 있다. 제도라는 형식논리로 볼 때, 기술혁신의 판단은 발명특허의 신규성과 진보성의 유무로 확인할 수 있다.¹⁹⁾ 이처럼 “특허법의 신규성과 진보성 등의 요건은 특허발명의 보호를 통해서 기술의 발전을 촉진하고 장려하는 기능을 수행한다”²⁰⁾고 한다.

반면, 특허제도는 “새로운 기술을 창작한 자에게 일정기간 독점적 이익을 부여함으로써 창작의 노고에 보답하고, 아울러 그 독점기간이 끝나면 누구나 당해 기술을 이용하도록 함으로써 산업발전을 도모하는 제도이다. 그런데, 사업발명과 같은 것은 일정한 기간이 지나 낡은 것으로 되면 전혀 쓸모없게 된다”²¹⁾는 한계도 지적된다. 이러한 경우, 특허법이 목적으로 하고 있는 기술혁신이 이루어질 수 있는 것인지 의문이 제기될 수 있다. 물론 모든 특허 영역에서 동일한 결과가 나오는 것은 아니라고 보며, 특히 기술사이클이 길지 않는 SW특허 분야에서의 특수성으로 보인다. 혁신의 원천은 “개개의 자원들보다는 자원들간의

19) 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이의 정도에 대한 확립된 판단기준은 없으나 적어도 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보 발전을 도모하고자 하는 특허제도의 목적(특허법 제1조)에 비추어 일용 발명의 진보성을 인정하는 것이 타당하다 할 것이고(대법원 1983.4.26 선고82후72 판결; 1989.7.11. 선고 88후516 판결 참조) 특허등록된 기술의 작용효과가 선행기술의 작용효과에 비하여 현저하게 향상진보된 것이 아닌 때에는 발명의 진보성을 결여한 것이라고 보아야 할 것이다. 또한 등록된 발명이 공지공용의 기존기술을 종합한 것인 경우에도 선행기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 있다거나 이로 인한 작용효과가 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과이상의 새로운 상승효과가 있다고 인정되고, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없다고 보여지는 경우 또는 새로운 기술적 방법을 추가하는 경우에는 발명의 진보성이 인정되어야 할 것이나(대법원 1987.9.29. 선고 85후25 판결; 1988.2.23. 선고83후38 판결; 1989.7.11. 선고 88후516 판결 참조) 그렇지 아니하고 공지공용의 기존기술을 종합하는데 각별한 곤란성이 없다거나 이로 인한 작용효과도 이미 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과이상의 새로운 상승효과가 있다고 볼 수 없는 경우에는 발명의 진보성은 인정될 수 없다 할 것이다. 대법원 1989.11.24. 선고 88후769 판결[특허무효].

20) 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010, 15면.

21) 이상정, 컴퓨터소프트웨어 관련 특허의 인정 범위와 한계, 지적소유권법연구 제3집, 1999, 293면.

연결고리에서 발생한다”²²⁾고 볼 때, SW의 기술혁신도 어느 한 기업이나 하나의 기술이 아닌 다양한 기술과 인력의 직간접적인 협력을 통해서 가져왔다는 점이 SW특성과 역사가 반증하고 있다.

III. 특허대상으로서 SW 발명

1. SW 발명

컴퓨터 프로그램 언어 자체는 물론 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체는 발명이 될 수 없다.²³⁾ 다만 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되는 경우에는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작 방법 및 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체는 자연법칙을 이용한 기술적 사상²⁴⁾의 창작으로서 발명에 해당한다.²⁵⁾

정보 기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 SW에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고,²⁶⁾ 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체

22) Melissa A. Schilling, 김길선 역, 기술경영과 혁신전략, McGraw-Hill, 2010, 21면.

23) “특허권은 그 보호대상을 기술적 사상(idea) 좀 더 구체적으로는 기술적 사상에 대한 응용(application)을 그 대상으로 하고 있고, 이에 반하여 저작권에서 사상은 보호대상이 되지 아니하며 사상의 표현(expression)을 그 보호대상으로 하고 있으므로, 보호대상에서 근본적인 차이점이 존재한다”고 한다. 김관식, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제, 법학연구 제23권 제1호, 2012, 554면.

24) 기술적 사상이 존재하지 않는 가운데 데이터, 수학적 공식, 추상적 사업방식 그 자체만으로는 아무리 컴퓨터 기록매체에 저장된 형태로 출원되었다 하더라도 발명에 해당된다고 볼 수 없다고 한다. 정상조·박준석, 지식재산권법, 홍문사, 2013, 83면.

25) 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2014, 3103-3104면.

26) 출원발명은 바코드스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 포함하고 있지만, 출원발명의 구성요소인 위 각 단계는 위 하드웨어 및 소프트웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니할 뿐만 아니라, 그 수단을 단지 도구로 이용한 것으로 인간의 정신활동에 불과하고, 위 각 단계로 이루어지고 위 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하는 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관찰관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관찰관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것

로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.²⁷⁾ SW에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다고 함은 SW가 컴퓨터에 의해 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 나아가 SW와 하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다.²⁸⁾

정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 SW에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 한편, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.²⁹⁾ 무엇보다도, 컴퓨터 관련 발명에서 영업방법 발명은 정보기술을 이용하여 구축된 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법 발명을 말하고, 이에 해당하려면 컴퓨터상에서 SW에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 이는 SW가 컴퓨터에 의하여 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, SW가 컴퓨터에 읽혀져서 하드웨어와 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말하고, 물론 발명으로서 완성되기 위해서는 청구항의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어 있어야 한다. 따라서 영업발명이 성립하려면, 전체로서 판단된 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안 되고, 컴퓨터 시스템 상에서 SW와 하드웨어의 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축됨으로써 컴퓨터나 인터넷이 단순히 이용되는 것 이상의 새로운 효과를 발휘

도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이 사건 출원발명은 제29조 제1항 본문의 '산업상 이용할 수 있는 발명'이라고 할 수 없다는 취지로 판단하였다. 대법원 2003.05.16. 선고 2001후3149 판결[거절사정(특)] .

27) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결[거절결정(특)].

28) 특허법원 2006.12.21. 선고 2005허11094 판결 : 상고[거절결정(특)].

29) 대법원 2008.12.24. 선고 2007후265 판결[거절결정(특)] .

할 수 있는 것이어야 한다.³⁰⁾ 이처럼 영업발명은 컴퓨터를 이용하는 것으로서 그 본질은 SW특허이다.³¹⁾

2. 특허에 의한 SW보호 논의

가. 특허법 개정 논의

특허청은 2011년 특허법의 개정을 통해서 물건의 발명에 SW를 명시적으로 포함하고, 아울러 인터넷 등 정보통신망을 통해서 유통되는 내용을 포함하는 실시의 개념을 다시 정의하고자 하였다. 그 배경은 “프로그램의 유통 구조의 변화에 따라 프로그램이 네트워크를 통하여 독립적으로 유통되고 있으나, 프로그램이 기록매체의 형태를 취하는 경우에는 보호가 가능하나 네트워크를 통해서 유통되는 동일한 프로그램은 보호되고 있지 않은 모순점을 해결할 필요가 있다는 점”³²⁾을 들고 있다. 그동안 특허청은 현행 컴퓨터관련발명의 심사기준에서 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체의 형태와 방법의 형태로 기재된 청구항만을 인정해 왔다.³³⁾

<표1> 특허법 개정(안)

현행법	2011년도 개정법안	2014년도 개정법안
제2조(정의) 1. ~ 2. 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도	제2조(정의) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. “실시”라 함은 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다. 가. 물건(컴퓨터 등 정보처리능력을 갖는 장치에 대한 명령의 집합으로서 특정한 결과를 얻	제2조(정의) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. “실시”라 함은 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건(프로그램 등을 포함한다. 이하 같다)을 생산·사용·양도(그 물건이 프로그램 등인

30) 특허법원 2007.06.27. 선고 2006허8910 판결 : 확정[거절결정(특)].

31) 조영선, 특허법, 박영사, 2012, 204면.

32) 특허청, 프로그램 관련 발명 특허법 개정 공개 토론회, 2011.6. 6면(김관식, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제, 법학연구 제23권 제1호, 2012, 551면 재인용).

33) 2002년 김순석 교수는 실시의 개념을 “가. 물건(프로그램 등을 포함한다. 이하 같다.)의 발명인 경우에는 그 물건의 생산·사용·양도·대여(그 물건이 프로그램 등에 해당하는 경우에는 전기통신 회선을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다.) 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위”으로 개정할 것을 제안한 바 있다. 김순석 외, BM 특허 보호를 위한 법제도 개선방안, 정보통신부, 2002.12, 152면.

또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위	<u>을 수 있도록 명령이 조합된 프로그램 및 컴퓨터 등 정보처리능력을 갖는 장치 처리용으로 공급되는 정보로서 프로그램에 준하는 것을 포함한다. 이하 같다.)의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도(정보통신망을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다.)·대여(정보통신망을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다.) 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다.)을 하는 행위</u> 나. ~ 다. (현행과 같음)	경우 정보통신망을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다)·대여(그 물건이 프로그램 등인 경우 정보통신망을 통한 제공을 포함한다. 이하 같다) 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위 나. ~ 다. (현행과 같음)
<신설>		4. “프로그램 등”이란 컴퓨터 등 정보처리능력을 갖는 장치에 대한 명령의 집합으로서 특정한 결과를 얻을 수 있도록 명령이 조합된 프로그램 및 컴퓨터 등 정보처리능력을 갖는 장치 처리용으로 공급되는 정보로서 프로그램에 준하는 것을 말한다.

이것은 특허법상의 물건에는 프로그램을 담은 매체만이 포함된다는 전제를 가진 결과였고, 이에 따라 모든 SW 특허는 형식상으로도 SW 또는 프로그램 자체가 아니라 그것을 담은 매체로서 등록되어야 했다. 특허청은 특허법 개정을 통해 특허법상 보호대상에 프로그램을 명시함으로써 물건의 개념을 둘러싼 위와 같은 혼란을 제거하려고 시도하는 것으로 알려져 있다.

SW의 특허성과 물건성을 둘러싼 “그동안의 불필요한 이견과 혼란을 제거한다는 점에서 볼 때, 이러한 특허법의 개정은 매우 적절한 것이라고 평가 된다”³⁴⁾는 주장도 있다. 그러나 2011년 특허법 개정은 관계부처의 반발로 이루어지지 못하였다고 한다.³⁵⁾

34) 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8, 411-412면.

35) 김관식, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제, 法學研究 第23卷 第1號, 2012.6. 552면.

향후 SW 유통방식은 SaaS 형태³⁶⁾가 보편화될 것으로 보이며, 앱을 통한 모바일 방식의 서비스로 확대될 것으로 예측된다. 따라서 SW특허의 발명과 실시에 대한 명확한 개념을 정립할 필요가 있다.

나. 특허청 심사기준 개선방안

2011년 특허법 개정 논의와 달리 특허청은 2014년 심사지침의 개정을 통해서 SW발명을 적극적으로 포섭하기로 정책방향을 정하였다. 그러나 이미 특허청은 심사기준에 따라 기록 매체에 따른 특허는 허여되어왔다. 다만 심사기준의 개정 취재는 명세서의 기재불비에 따른 거절이유통지에 대한 관행을 개선한다는 것이나, 판례를 통해 확인한 바로는 그 것이 미완성 발명³⁷⁾인지 또는 기재불비인지 명확하지는 않다.³⁸⁾ 즉, “영업발명의 각 단계들이 SW와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 않을 뿐 아니라, 사용 목적에 따른 각 단계별 정보의 연산 또는 가공이 어떻게 실현되는지에 대해 명확하게 기재되어 있지도 않아, 컴퓨터상에서 SW에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있지 않으므로, 전체적으로 볼 때 구 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 할 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허법 제2조 제1호, 구 특허법 제29조 제1항에 관한 법리오해 등의 위법이 없다”³⁹⁾라는 것이다.

이와 같이, 특허청이 주장하는 바와 같이 기재불비가 문제였다면 오히려 이는 발명의 성립성 판단에 있어서 형식적 요건만을 판단해온 것은 타당하지 않은 관행이었다는 비판을 받을 수 있다는 점은 부인하기 어렵다. 왜냐하면, 실제 발명의 실시에 대한 판단이라면, 기재불비의 형식적 요건은 보정명령을 통해서 해결할 수 있기 때문이다.⁴⁰⁾

36) SW as a Service의 약어로, 인터넷을 통해서 SW를 이용할 수 있는 서비스를 말한다.

37) 특허를 받을 수 있는 발명은 완성된 것이어야 하고 완성된 발명이란 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명으로 그 판단은 특허출원의 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 할 것이다. 대법원 1994.12.27. 선고 93후1810 판결[거절사정]

38) 조영선, 특허법, 박영사, 2011, 86면.

39) 대법원 2008.12.11. 선고 2007후494 판결.

40) 잘못된 기재를 정정하는 경우란 정정 전의 기재내용과 정정 후의 기재내용이 동일함을 객관적으로 인정할 수 있는 경우로서, 청구범위의 기재가 오기인 것이 명세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에 그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 말한다. 대법원 2007.6.1. 선고 2006후2301 판결.

<그림 2> 심사기준 개정에 따른 보호대상



자료 : SPRi포럼(2014.7.22.)

2014년 7월 개정 전 심사기준에서는 청구항이 프로그램, 프로그램 제품인 경우 허용되지 않고 있었으나, 개정 심사기준에서는 컴퓨터 SW 관련 발명의 성립성을 만족하면, 청구항이 '프로그램', '프로그램 제품'인 경우에도 허용된다. 이러한 점에서 심사기준의 변경이 가져오는 것은 특허발명의 실체가 변한 게 아니라, 기재불비에 관한 사항이라고 한다.⁴¹⁾

<그림 3> 심사기준 개정에 따른 청구항 기재형식

청구항 기재형식	개정 전	개정 후
컴퓨터에 △단계, □단계를 실행시키는 <u>컴퓨터프로그램</u>	×	○
스마트폰에 △기능, □기능을 실행시키는 <u>애플리케이션</u>	×	○
컴퓨터에서 △단계, □ 단계를 실행하는 <u>컴퓨터프로그램을 기록한 기록매체</u>	○	○
△ 기능, □ 기능을 수행하는 <u>컴퓨터장치</u>	○	○

자료 : 특허청(2014)

그러나 특허청이 개선이라고 하는 내용은 그림에서와 같이, 기존의 심사지침과 비교했

41) 미완성발명이라든 심사지침 이후라도 거절되는 것은 당연하나, 지침의 변경으로 등록되도록 변경하는 것은 실제적 변경이 없음을 반증한다.

을 때 HW나 매체에 저장된 개념은 다르지 않다. 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 청구항은 SW발명의 범주에 포함된다. 도표에서 ‘컴퓨터프로그램’이 그에 준하는 용어(애플리케이션 등)로 기재된 경우에도 허용된다. 한편, ‘매체에 저장되지 않은 컴퓨터프로그램’은 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 않는다. 이는 하드웨어와 결합되어 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터프로그램 형식도 특허를 부여하기 위해 신설되었기 때문이다.

3. SW의 인터넷 유통과 특허 실시

가. 인터넷 유통과 실시

앞으로는 SW를 포함한 인터넷 발명은 인터넷을 통해서 특허가 실시되는 구조가 기본이 될 것으로 예견된다.⁴²⁾ 인터넷을 통해 이용에 제공되는 방식도 또한 유통에 포함될 수 있다. 물론 인터넷은 매체를 독립한 구조를 갖기 때문에 다운로드나 전송 형태의 서비스도 인터넷의 유통이라고 볼 수 있다. 전통적인 방식의 점유이전이 없다고 하더라도, 인터넷의 유통은 발명특허의 실시에 포함될 가능성을 배제하지 못한다.

특허법은 발명을 이용하는 행위를 실시라고 하는데, 물건의 발명과 방법발명을 포함한다. 먼저, 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 말한다. 다음으로, 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위를 말한다. 끝으로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.

인터넷 실시는 인터넷을 통해서 발명특허를 실시하는 것을 말한다. 인터넷 자체에서 실시되는 것은 물건의 방법으로 보기 어렵다. 왜냐하면, 인터넷을 이용하는 것이 물리적인 결과물로서 물건이 대상이 될 수 없기 때문이다.

42) 이미 中山信弘 교수는 클라우드 컴퓨팅 환경에서의 SW의 이용에 대해 “앞으로는 기록매체로서 판매하지 않고 온라인으로 소프트웨어를 이용하는 사업이 발전할 것이다. 특히 사용자가 스스로의 컴퓨터에 프로그램을 축적하지 않고 온라인으로 호스트 컴퓨터를 이용하여 필요한 부분만을 보내주는 업종도 번성할 것이다. 그러한 이용행위가 과연 침해를 구성하는가. 즉 그러한 이용행위가 특허법 제2조에 규정되고 있는 실시(생산 등)에 해당하는가 라는 점이 논의의 대상이 될 것이다”라고 1998년 그의 저서인 특허법(본 서는 2001년 한국어로 번역되었다)에서 적고 있다.

나. 인터넷 실시에 따른 OSP 책임

인터넷 실시가 가능하게 될 경우에는 실제 OSP(Online Service Provider)를 통해 유통되는 문제에 대한 검토가 필요하다. 먼저 OSP의 직접 책임을 보면, OSP는 이용자가 정보를 게시하거나 유통시킬 수 있는 공간이나 서비스를 제공하는 사업자를 말한다. 따라서 직접적으로 정보를 유통시키는 사업자는 OSP로 보기는 어렵다. 물론 직접 정보를 유통시키는 경우에는 OSP라기 보다는 콘텐츠제공자(CP)로 보아야 할 것이다. 이 경우 OSP가 직접적인 침해에 대한 책임을 지는 것은 자기책임의 원리에서 당연하다. 즉, OSP가 제공하는 플랫폼에서 침해되는 SW를 직접 유통시키는 경우라면 특허권 침해에 대한 책임을 지는 것은 법리적으로 달리 볼 수 없기 때문이다.

두 번째로 OSP의 방조 책임을 보면, OSP는 기본적으로 저작권이나 정보를 침해하는 자가 아니다. 다만 자신의 서비스를 통해서 다른 사람이 저작권이나 정보를 무단으로 유통시키는 경우가 발생하기 때문에 일정한 요건을 부여하고 있으며, 해당 요건을 만족시키지 못할 경우에는 권리 침해에 대한 책임을 부여하는 것이다. 저작권법 및 정보통신망법에서 규정하고 있는 것이 바로 OSP의 책임에 대한 규정이다. 따라서 해당 요건을 만족할 경우에는 이용자의 침해책임에도 불구하고 면책하고 있는 구조이다. 저작권법은 사적복제를 허용하고 있다. 인터넷상에 올려진 SW를 다운로드 받아 이용하는 행위 자체는 저작권을 침해한 것으로 보기 어렵다. 그러나 SW 특허의 경우에는 사적복제 항변을 받아들일 수 없게 되는 문제가 발생한다.⁴³⁾

세 번째로 특허법은 직접 책임 이외에도 간접책임에 관한 규정을 두고 있다. 즉, 특허법상 간접침해 요건에 대해 (1) 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, (2) 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 등 각각의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 규정하고 있다.⁴⁴⁾

43) 다만, 사적복제의 경우에는 업으로 실시하는 경우가 아니기 때문에 특허권의 침해로 보기는 어려울 것이다. 다만, OSP를 통해서 사적복제가 이루어질 경우에는 방조책임에 문제될 수 있다.

44) ‘침해로 보는 행위’(강학상의 간접침해행위)라 하여 현실로 특허권 또는 전용실시권(이하 ‘특허권’ 등이라 약칭한다.)의 침해로 보기 어려운 예비단계의 행위를 침해행위로 의제하는 규정을 두고 있는 바, 여기에서 위 제64조에 해당하는 간접침해행위에 대하여 특허권등 침해의 민사책임을 부과하는 외에 위 법 제158조 제1항 제1호(특허권등을 침해한 자에 대한 처벌규정)에 의한 형사처벌까지 가능한가가 문제될 수 있는데, 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙에 비추어, 또한 특허권등 침해의 미수범에 대한 처벌규정이 없어 특허권등 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에

다. OSP 면책규정의 도입

OSP의 행위가 간접침해를 구성하는지의 여부와 관련하여, 우리나라의 경우 간접침해가 인정되기 위해서는 물건발명의 경우 특허된 “물건(컴퓨터프로그램)의 생산에만 사용되는 물건”을 “생산, 양도(전송), 대여, 수입” 등의 행위를 할 것이 요구되는데, OSP의 양도(전송) 행위의 대상이 되는 컴퓨터프로그램은 특허된 ‘물건’에 해당할 뿐으로, 특허된 “물건(컴퓨터프로그램)의 생산에 사용되는 물건”으로 볼 수 없고, 더욱이 “특허된 물건(컴퓨터프로그램)의 생산에만 사용되는 물건”으로는 더욱 볼 수 없으므로, 결국 OSP의 전송행위에 대하여 간접침해 책임을 물을 수 없게 된다.⁴⁵⁾ 그러나 SW는 복제하는 행위가 새로운 SW가 생성되는 개념으로 볼 수 있기 때문에 생산의 개념에 포함될 가능성도 작지 않다. 또한 SW를 이용하여 새로운 결과물을 만들어낸다면 이 또한 생산의 개념으로도 볼 수 있다.⁴⁶⁾ 이처럼 SW특허는 독립된 거래제로서의 유통될 수 있기 때문에 OSP에게는 예기치 못한 문제를 가져올 가능성이 있다.

직접 책임이나 간접책임 보다는 방조책임의 가능성이 더 클 수 있다. 따라서 OSP에게는 서비스의 안정성을 위해, 저작권법 유사한 OSP면책 규정을 두는 것이 필요하다. 특허법에 OSP면책 규정을 두는 것이 법체계에 다른 이해관계에서 어렵다면, OSP관련 특별법을 마련하는 것도 고려해야 한다. OSP의 면책 규정과 관련하여, 방조책임에 있어서 이용자가 계

도 특허권등 직접침해의 예비단계 행위에 불과한 간접침해행위를 위 벌칙조항에 의하여 특허권 등 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성등에 비추어 볼 때, 위 제64조의 규정은 특허권자 등을 보호하기 위하여 특허권 등의 간접침해자에게도 민사 책임을 부과함으로써 특허권자 등을 보호하기 위한 취지의 정책적 규정일 뿐 이를 특허권등의 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아닌 것으로 봄이 옳을 것이다. 대법원 1993.02.23. 선고 92도3350 판결[특허법위반]

45) 김관식, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제, 법학연구 제23권 제1호, 2012, 569면; 김순석 외, BM 특허 보호를 위한 법제도 개선방안, 정보통신부, 2002.12, 156면.

46) 간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다. 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다. 대법원 2009.09.10. 선고 2007후3356 판결[권리범위확인(특)]

시하는 불법 SW를 공유하는 경우는 해당 게시물에 대해 저작권자의 게시중단 요청에 따른 경우에는 이에 응하여 진행하면 된다. 기술적으로 불가능한 경우라면 면책된다. 즉, 온라인 서비스제공자가 제102조 제1항에 따른 조치를 취하는 것이 기술적으로 불가능한 경우에는 다른 사람에 의한 저작물등의 복제·전송으로 인한 저작권, 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리의 침해에 대하여 책임을 지지 아니한다(저작권법 제102조 제2항). 그러나 SW의 경우에는 이러한 면책규정을 두고 있지 않기 때문에 OSP는 그 책임 범위가 넓어지게 되는 문제가 발생한다.

4. 소결론

SW특허 허여의 쟁점은 기록된 매체를 전재한다는 점에서, SW의 기술적 사상을 바탕으로 특허출원이 가능한지 여부이다. 심사기준 등에서는 SW가 저장된 기록매체를 특허의 요건으로 하고있는데, 개발되지 않는 SW는 요건을 구성하지 못하기 때문에 방법의 성립자체가 불가능하다. 따라서 매체 중심의 SW특허를 위해서는 심사기준이 보다 명확하게 규정될 필요가 있다. 이러한 점 때문에 유연성이 떨어지지만, 법적 안정성과 연속성을 유지한다는 점에서 일본 사례⁴⁷⁾와 같이 실시행위를 추가하는 특허법 개정이 바람직하다는 견해가 있다.⁴⁸⁾

IV. SW특허와 기술혁신의 관계

1. 기술혁신을 위한 선택

특허와 저작권법의 비교를 통해 어떠한 득실이 있는 지 살펴보고자 한다. SW의 보호 논의는 저작권법과 특허법 사이에 이해의 충돌이 있으며, 저작권법의 한계 내지 특허법의 한계도 지적되고 있다. 어느 하나의 법체계가 합리적이라는 결론을 내리기 쉽지 않다. 저작권법과 특허법이 의도한 바가 다르고, 법체계와 성질이 서로 상이하며 동일한 대상에 대해

47) 일본도 2002년 2011년도 특허법 개정안과 같은 형태로 개정한 바 있으나, 법개정 이후에 특별하게 문제된 사례는 없다고 한다.

48) 강흥정, 컴퓨터 소프트웨어의 특허보호에 대한 연구, LAW&TECHNOLOGY 제8권 제3호, 2012, 57면.

다른 법률의 적용이 불가능하다고 보기 어렵기 때문에 양법의 적용가능성도 배재할 수 없다. 다만 이를 수범하는 입장에서 동등 대상에 대해 서로 다른 법률의 적용과 해석에 따라 법적 안정성이 훼손당할 수 있다⁴⁹⁾는 점이 한계이다. 물론 SW 개발자의 입장에서 저작권보다 특허에 의한 보호를 희망하기도 하는데, 그 이유로는 “첫째, 프로그램 개발 과정에서 알고리즘이라는 아이디어를 보호받을 수 있다는 점, 둘째, 모방에 의하지 않고, 독자적으로 개발한 것에 대하여도 특허권 행사가 가능하기 때문에 권리 취득 후에 절대적 권리를 행사할 가능성이 있다는 점, 셋째, 자사가 프로그램에 대한 저작권을 취득한 후라도, 타사가 당해 프로그램의 알고리즘에 대하여 특허권을 취득할 가능성이 있다”⁵⁰⁾는 점을 든다. 그러나 이러한 주장은 항상 설득력을 얻는 것은 아니다.

2. SW특허에 대한 저작권법적 고찰

가. 동일한 SW의 개발

저작권은 창작과 동시에 권리가 발생한다. 반면 특허는 특허청의 등록심사를 거치고 특허 요건을 갖춘 경우에는 등록될 수 있다. 따라서 저작권은 동일한 SW를 허용하나, 특허는 동일한 SW를 개발한다고 하더라도 후행 개발은 특허권 침해로 구성하게 된다. 특허제도가 발명의 진흥을 목적으로 함에도 불구하고, 동일한 SW의 개발에 많은 시간과 노력을 투자했다고 하더라도, 먼저 특허등록을 받은 사람이 모든 권리를 갖기 때문에 특허법의 목적규정과 충돌이 발생한다.

이에 대한 비판으로 “특허권으로 보호하면 경쟁자는 스스로 선행 특허가 있는지를 조사하여야 하며, 저작권의 경우와 달리 우연의 일치라는 항변은 인정될 수 없다. 무지는 변명이 될 수 없다. 그러나 도대체 어떤 기술 내용이 특허되는지 잘 모른다. 또 프로그램언어가 다양하여 알기 어렵다. 초록 속에 컴퓨터, SW, 프로그램, 알고리즘이라는 단어가 없는 SW 특허도 많다. 경고장이 날아올 때까지 자기가 남의 특허를 침해하고 있다는 사실을 모른

49) 컴퓨터프로그램보호법 설계자인 송상현 교수는 “특허법상 보호하고자 하는 경우에는 엄격한 특허요건을 충족시킴이 어렵고 프로그램이 특허된다 해도 그 침해를 찾아내기도 불가능하며 그와 같은 특허가 과연 어떠한 효력을 갖는가 하는 점도 명확하지 않다. 나아가 특허를 얻는 데는 비용도 들고 시간도 수십년씩 장기간이 소요되어 그 동안 컴퓨터프로그램의 수명이 다할 뿐 아니라 그 내용이 공개되어 침해를 초래하는 등 불이익이 있어 특허법은 프로그램보호를 위한 상태라고 할 수 없으므로 특허제도의 활용을 통한 보호는 회의적”이라고 적고 있다. 송상현·김문환·양창수, 컴퓨터프로그램보호법 축조연구, 서울대학교출판부, 1989, 11면.

50) 전삼현, 프로그램지적재산권 담보제도 수립을 위한 법적 연구, 프로그램심의조정위원회, 2000, 52면.

다”⁵¹⁾는 비판은 생각해볼 만하다.

나. 저작권법과의 중복보호⁵²⁾

특허법의 보호범위와 저작권법의 보호범위는 아이디어의 표현이라는 점에서 차이가 없다. 다만 저작권법은 문언적으로 표현된 것을 보호하기 때문에 특허와 같이 비문언적인 부분에 대해서는 보호가 어렵다. 저작권법이 보호하는 것이 바로 표현이므로, 기술적인 사상 자체를 보호하지 못한다는 비판은 SW특허를 주장하는 입장을 대변하는 논리이다. 이는 아이디어표현2분법 체계에서 한계이자, 컴퓨터프로그램이 갖는 한계이다. 이러한 이유 때문에 저작권법의 보호범위와 특허의 보호범위가 중복될 수 있다는 주장도 또한 설득력을 갖는다. 이러한 중복보호에 대해서는 저촉관계를 통해서 해결할 수 있다는 주장이다.⁵³⁾

그러나 후행 개발자가 선행 개발자의 SW를 확인하는 것은 사실상 쉬운 일이 아니다. 따라서 특허청에서 SW의 심사과정에서 해당 SW의 선행기술 여부를 조사하는 것이 아닌 미리 개발자의 요구사항으로서 선행기술을 조사해주는 업무를 추진하는 것도 SW발전에 있어서 중요한 역할이라고 본다.

다. 부실권리와 비용의 발생

저작권법은 창작과 동시에 권리가 발생하며, 어떠한 형식적 요건을 요구하지도 않는다. 권리를 획득하는 데 있어서 비용도 발생하지 않는다. 그렇지만 특허는 특허권이라는 권리를 획득하기 위해서는 작지 않는 비용이 소요된다. 출원시 발생하는 비용은 물론, 권리를 유지하기 위한 관납료도 매해 납부해야한다는 점도 권리자에게는 부담이다. 더욱이 관납료는 매해 누진세 형식으로 증가한다는 점도 고려해야 한다. 물론 저작권법의 경우도 등록제도를 운영하고 있으나, 이는 권리발생 요건이 아닌 권리자 내지 권리의 공시에 불과하기 때문에 비용이 상대적으로 저렴하다.

특허법과 달리 저작권법은 부실 권리라는 개념이 없다. 창작과 동시에 발생한 권리는 저작자가 스스로 창작한 경우라면 침해를 구성하지 아니한다. 그러나 특허는 발명자가 독자적으로 발명하더라도, 타인의 권리를 침해한 경우라면 어떠한 대가도 받을 수 없다. 설령 심사과정에서 심사관에 의해 거절이유를 발견하지 못하여 특허등록이 되었다고 하더라도,

51) 이상정, 컴퓨터프로그램보호방법의 제검토, 서울대학교 법학 제48권 제1호, 2007, 117면.

52) 盛岡一夫, 著作権の 法的 性質, 著作権과 民法의 現代의 課題, 法學書院, 2003, 60頁.

53) 김관식, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제, 法學研究 第23卷 第1號, 2012.6, 575면.

여전히 이해관계자에 의한 특허무효 심판이나 소송의 제기가 가능하다.

더욱이 SW 특허나 영업방법 특허는 상대적으로 물질특허 등에 비해 추상적이기 때문에 권리의 무효화가 크다. 이러한 점은 역으로 권리범위를 확대시킬 수 있다는 점으로 특허피 물에 의해서 특허침해 소송에 활용되고 있다.

라. 권리 제한

저작권법의 목적은 특허법과 비슷한 의도를 가지고 있다. 즉, 저작권 및 이에 인접하는 권리의 보호는 물론 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 발전을 가져오는 것이라는 점에서 특허법과 비슷하다. 지적재산권의 이용이 없으면 무용지물에 불과하기 때문에 그 이용을 장려하는 것이 지적재산권법의 목적이다. 이러한 맥락에서 저작권법은 사적복제 등 저작재산권의 제한 규정을 두고 있다. 권리자에게는 치명적일 수도 있는 제한규정을 두는 이유는 무엇일까? 이는 공정한 이용을 도모하자는 공공정책적 판단에 따른 것이다. 저작물을 이용하고자 하나, 비용을 지불할 수 있는 능력이 되지 못한 경우나 또는 너무나 현실적이지만 실제 누가 불법복제를 했는지를 확인하는 비용이 더 소요되는 경우에 입법자의 결단이 내려진 것이다.

또한 저작권법은 호환 등을 위하여 역분석을 포함한 공정이용(fair use)을 허용하고 있다. 역분석은 예외적이기는 하지만, 복제권의 침해를 면책해주는 역할을 한다. 그러나 특허는 이러한 면책이나 제한 규정을 두지 않고 있다. 예외적으로 연구 등을 위해서만 가능하다. 저작권법은 인용의 경우에는 가능하고, 공정이용의 경우에는 일정한 조건을 갖출 경우에는 저작권 침해책임에서 벗어나게 된다. 또한 OSP에 대해서도 면책 규정을 두고 있다. 이러한 점은 저작권법 체계가 갖는 유연성을 말해주는 것이다. 그러나 특허는 유연성이 상대적으로 약하다. 따라서 프로그램 특허규정과 충돌이 일어난다. 즉, 아이디어, 알고리즘 등 보호 배제된다는 점이다.

실상 SW를 저작권이나 특허로 보호한다고 하더라도, 기술 사이클이 짧기 때문에 과도한 보호기간으로 볼 수 있다. 퍼블릭도메인에 먼저 도달할 수 있는 것은 특허권이기 때문에 보호기간만으로 볼 때면 특허제도가 보다 합리적이라고 할 수 있다. 그러나 SW특허가 만료된 이후 다시 저작물로 보호를 주장할 경우에는 이를 방지할 방법이 없다. 이러한 경우에는 권리남용으로 해결하는 방법이 있겠지만, 이 또한 남용의 주장자가 입증을 해야하는 부담이 작용하게 된다.⁵⁴⁾

많은 경우, 이미 누적된 특정 SW의 특허기간이 종료하면 그 이후부터 특허침해로 인한

법적 제재나 로열티 지급의 부담으로부터 벗어난다는 실로 중대하고도 커다란 의미를 가지게 된다. 따라서 SW의 경우 특허기간이 끝난 후에는 쓸모가 없어지는 것이 아니라 특허된 SW를 포함하는 모든 SW 개발자가 무상으로 사용할 수 있게 된다는 이익이 남게 된다고 주장한다.⁵⁵⁾ 그러나 SW는 누적적, 점진적으로 발전해온 것이라고 하지만, 시기성을 상실할 경우에는 독점기간이 끝난 후에는 거의 쓸모없게 되어 사회가 거의 이익을 받지 못한다.⁵⁶⁾ 이러한 점을 무시하고, 특허가 만료되면 누구나 쓸 수 있다는 주장은 SW산업 현장에서 용인되기 어려운 주장이다.

3. SW의 기술혁신에 대한 우려

가. 선행기술 분석

선행기술에 대한 분석은 부실풍허를 배제할 수 있는 기본적인 요건이다. 그렇기 때문에 SW특허에서 무엇보다 중요한 것은 신규성, 진보성을 판단하기 위한 선행기술(prior art)에 대한 데이터베이스의 구축이다. 또한 심사관이 해당 기술에 대한 기술심사가 제대로 이루어질 수 있는지에 대한 검증이 요구된다. 이러한 이유 때문에 “SW의 특허출원 및 등록과정에서 특허청이 충분한 데이터베이스를 갖출 수 있는지, 제한된 수의 심사관들이 다양한 SW의 진보성을 충분히 심사해낼 수 있을지, 그래서 자격미달의 SW에 대하여 특허가 부여되거나 또는 그 반대의 경우가 생기지 않을지 등의 점을 주시하지 않을 수 없다”⁵⁷⁾고 한다. 이와 유사한 의견이지만 “영업발명 특허에 과제는 심의 자체가 되는 선행기술 및 문헌에 관한 적절한 데이터베이스의 구축과 이를 활용한 심사관들의 지속적인 학습기회 부여를 통하여 부적절한 영업발명 특허가 양산되지 않도록 노력하는 데 집중되어야 할 것”⁵⁸⁾이라는 지적도 있다.

나. 특허 문서의 효용성

특허명세서에는 발명자가 작성하는 문서가 아닌 특허사무소의 전문가에 의해서 만들어진

54) 아이디어 위주로 개발된 SW이기 때문에 공유영역에 포함된다. 실제 보호받는 것은 표현이다. 따라서 특허권이 만료된 SW를 저작권법으로 보호받는 것은 어렵게 된다.

55) 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8, 410면.

56) 이상정, 컴퓨터 소프트웨어 관련 특허의 인정범위와 한계, 지적재산권법연구 제3권, 1999, 302면.

57) 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8, 417면.

58) 손경한 편저, 신특허법론, 법영사, 2005, 53면.

문서이다. 물론 최종적으로 변리사가 검수한다고 하지만, 기본적으로 명세서의 작성은 표준화된 양식에 따라서 작성되기 때문에 개발자가 이를 이해하기는 쉽지 않다. 더욱이 기술을 글로써 표현하기 때문에 발명자와 특허전문가의 이해가 상이할 수 있다는 점도 고려되어야 한다. 특허 명세서의 청구항에 따라서 특허침해 여부, 또는 특허 무효 여부가 판단되기 때문에 특허 문서의 효율성을 담보하기가 쉽지 않다는 주장도 타당하지 않은 것은 아니다.

<표2> SW특허를 반대하는 이유

	주요 내용
SW 배포	SW의 배포를 차단한다. 많은 SW의 개발과 사업모델은 프로그램의 무료 배포에 기반을 두고 있는데, SW 특허는 이런 모델 자체를 금지할 수 있다.
표준과 호환성	SW 특허는 필수적인 기능을 사용하지 못하도록 하기 때문에 표준과 호환성에 방해가 된다.
특허 침해 회피	특허 침해를 피하기 위해서는 특허 조사를 해야 하지만 현실적으로 불가능하기 때문에 특허 침해를 피할 수 없다.
특허 문서	공개된 특허를 통해 얻을 수 있는 정보는 기술로서의 가치가 없다. SW 특허 문서는 너무 난해해 읽기도 어렵다. 마이크로소프트의 개발자들조차 특허 문서를 읽지 않는다.

자료 : 오픈넷(2014)

다. NPE(특허관리회사)의 대응

NPE(Non Practicing Entity)에 의한 특허권의 실시 없이 침해를 주장하는 경우가 문제이다.⁵⁹⁾ 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 특허권자 또는 전용실시권자가 침해금지 등의 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(특허법 제126조). 이러한 금지청구를 할 경우에는 실시자가 받는 경제적인 타격은 작지 않다. 물론 특허권을 일정기간 내에 실시를 의무화하고 있으며, 법적 유예기간 내에 행사하는 것을 문제 삼기는 어렵다. 이러한 이유 때문에 실상 NPE가 산업계에 미치는 영향을 작지 않기 때문에 특허제도의 보완이 필요하

59) “특허괴물에게 있어 특허권이라는 제도는 기술발전이나 산업발달이라는 본래의 목적에 봉사하는 대신 거액의 합의금을 중심으로 전략적인 영리추구의 수단으로 악용된다는 데 문제가 있다”고 한다. 조영선, 특허법, 박영사, 2011, 510면.

다. 권리구제를 받기위해서는 실시를 요건으로 할 필요성이 커지고 있다. 개인적으로도 실시 없이 침해해 주장하는 것은 문제이며, 발명권과 같은 원리를 실시 없는 특허의 경우에 제도화하는 것이 이를 해결할 수 있는 방법 중 하나이다.

라. 특허 남용

현행 특허법은 1963년 특허법과 비교할 때, 권리남용⁶⁰⁾이나 강제실시⁶¹⁾에 관한 규정이 없다. 대신 제정제도를 두고 있으나, 제정제도가 남용의 입법취지를 승계하고 있다고 하더라도,⁶²⁾ 실제 이용할 수 있는 한계가 있으므로 이에 대한 대비가 필요하다.

실 사례에서 대법원은 “원심이 토너 카트리지의 본건 특허 레이저 프린터의 ‘사용’에 필요한 예정된 소모품에 불과하다는 이유로 위 간접침해에서 말하는 ‘생산’의 개념에 포함되지 아니하고, 따라서 피신청인의 이 사건 토너 카트리지의 제조·판매는 신청인의 특허권을 침해한 것이 아니라고 판단한 것은 위 ‘생산’의 법리를 오해함으로써 이 사건 결정 결과에 영향을 미쳤다 할 것이니, 이 점을 지적하는 재항고이유는 이유 있다”⁶³⁾고 판시한 바 있다.

60) 1963년 특허법 제45조의2 (특허권의 남용) ① 특허권자 기타 특허에 관하여 권리를 가진 자는 그 권리를 남용하지 못한다.

②다음 각호의 1에 해당하는 때에는 특허에 관한 권리를 남용한 것으로 본다.

1. 국내에서 실시가능한 특허발명이 그 특허허여후 3년이상 정당한 이유없이 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되지 아니한 때
2. 특허허여후 3년내에 특허품·특허식물·특허기술 또는 특허방법에 의한 생산품에 관하여 정당한 이유없이 적당한 정도와 조건으로 수요를 충족시키지 못한 때
3. 특허권자가 실시권의 허락을 부당하게 거부하여 산업이나 국가 또는 국내 거주자의 사업에 손해를 가하였을 때
4. 방법발명에 의한 특허의 경우에 그 권리의 범위에 속하지 아니하는 방법에 의하여 물건을 생산하여 타인에게 부당하게 손해를 가하였을 때

③전항각호의 1에 해당하는 때에는 특허국장은 제45조의 규정에 준하여 특허권을 취소하거나 강제실시권을 허여할 수 있다.

④실시권자가 제2항 각호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는 특허권자는 그 실시권의 취소를 청구할 수 있다.

61) 1963년 특허법 제45조 (부실시의 경우의 강제실시 또는 특허취소) ① 특허권자가 특허를 받은 후에 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에 공익상 필요하다고 인정될 때에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 그 실시권을 타인에게 허여하거나 또는 그 특허를 취소할 수 있다. <개정 1963.3.5>

②전항의 규정에 의하여 실시권이 허여된 후 계속하여 3년 이상 정당한 이유 없이 그 실시권자가 그 발명을 국내에서 실시하지 아니하는 경우에는 특허국장은 이해관계인의 청구에 의하여 직권으로써 그 실시권을 취소할 수 있다.

③특허권자 또는 청구인은 제1항의 규정에 의한 실시권의 허여나 전항의 규정에 의한 특허취소의 처분 또는 전2항의 청구의 각하에 대하여 불복이 있을 때에는 그 결정을 받은 날로부터 40일 이내에 법원에 소송을 제기할 수 있다.

④제1항의 규정에 의하여 실시권을 허여하는 경우에는 특허국장은 보상금에 대하여도 이를 결정하여야 한다.

62) 권영준, 특허권 남용의 법리와 그 관련 문제, 산업재산권 제36호, 2011.12.

이에 대해 “토너 카트리지는 신청인의 특허발명의 하나의 구성요소에 해당할 뿐이고 토너 카트리지 자체가 특허발명에 해당되지는 않고, 따라서 특허권 침해 가능성 또는 위협성이 없음에도 불구하고 토너 카트리지의 생산을 간접침해라고 주장하는 것은 부당한 특허권의 확대이고 특허권의 남용에 해당되는 것”⁶⁴⁾이라는 비판이 있다. 또한 “피신청인의 부품생산을 간접침해라고 보는 것은 특허권의 부당한 확대로서 그 인센티브로서의 긍정적 기능보다는 공유기술에 대한 사용을 부당히 억제함으로써 기술발전을 저해하는 부정적 기능 더 크다”⁶⁵⁾고 한다. 이처럼 특허제도의 운영상의 문제점으로 인하여 기술발전을 저해할 수 있다는 우려가 있으며, 특허등록된 기술을 실시하지 않으면서 특허침해를 주장하는 것도 기술발전을 이끌 수 있는지 의문이다. 그렇지만 비실시 행위에 대해 특허법은 실시를 강제할 수 없다. “특허권자의 권리행사의 대표적인 방법은 금지청구와 손해배상청구라 할 것인데, 금지청구가 지나치게 쉽게 인용되거나 과도한 손해배상액이 인용된다면 많은 특허괴물이 특허권을 남용할 여지가 많아지게 되므로, 금지청구의 적정한 인용 및 손해배상액의 합리적인 산정은 특허제도의 남용을 방지하는 데 있어 매우 중요한 의미가 있다”⁶⁶⁾고 한다. 실제 SW는 특허명세서에 담긴 그 기술내용을 이를 이용하고자하는 자가 이해하기가 쉽지 않다는 본질적인 문제가 있다. 이러한 점에서 “SW의 경우에는 그 복잡하며 상세한 처리과정을 청구항에 기재함에 있어 특허 청구범위가 모호해지고 따라서 제3자가 어떤 기술이 특허되었는지 알 수 없을 가능성이 높은 것은 어느 정도 사실이며, 이에 대한 보완장치는 필요할 수 있다”⁶⁷⁾는 주장은 설득력을 갖는다. NPE 등에 의한 특허남용의 대표 사례는 특허권의 실시 없이 침해나 금지청구를 주장하는 경우를 들 수 있다.⁶⁸⁾

4. SW특허와 기술혁신과의 상관성

기술은 변화하는 것이 그 본질적인 속성이다. 변화하지 않는 기술은 실용성을 갖추었다고 보기 어렵다. 또한 기술은 기존의 기술의 개선을 통해서 발전하기도 한다.⁶⁹⁾

63) 대법원 1996.11.27. 자 96마365 결정[특허권등침해금지가처분].

64) 손경한 편저, 신특허법론, 2005, 법영사, 40면.

65) 손경한 편저, 신특허법론, 2005, 법영사, 40면.

66) 김기영, 소프트웨어 특허 침해에 대한 구제, LAW&TECHNOLOGY 제3권 제4호, 2007.7, 80면.

67) 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8, 408면.

68) 물론 이러한 것이 특허제도를 무시한 것이라고 단정할 수 없다. 만약 어떠한 방법으로든 보완장치가 마련되지 않는다면 SW특허에 대한 NPE들의 무차별적 침해소송을 제어하기 어렵고, SW특허의 본질적인 한계에 직면하게 될 것이다.

69) “기술은 기본적으로 고정된 것이 아니라 계속 변하는 실체인 것이다. 그러한 관계로 정적인 의미

SW는 누적적으로 발전하며, 호환성, 표준화 등 상호보완적 역할을 한다. 이러한 점 때문에 어느 한 쪽이 권리를 행사할 경우에 SW의 상생시스템이 약화된다. SW의 보호는 실시를 통해서 공유하는 것이 기술의 발전을 이끈다. 그러나 보호는 상대의 실시를 제한하는 것이기 때문에 특허법의 목적달성을 어렵게 한다. 즉, 보호만을 위해 특허를 받게 되면 이의 실시는 어렵게 되며, 원래 의도했던 기술의 진보 및 이의 진보를 통한 삶의 가치나 국민경제의 발전이라는 특허법의 궁극적인 목적을 달성하기 어렵게 된다.⁷⁰⁾

SW에 있어서 혁신은 기술의 개방과 폐쇄를 통해서 상대적인 차이를 두고 발전해 왔다. 리눅스 등 오픈소스 SW가 대표적인 개방형 혁신을 시도한 주체라면, 애플이나 MS와 같은 폐쇄형 내지 상업형 SW는 폐쇄형 혁신을 주도해온 주체이다. 전자는 소비자의 욕구가 바로 SW에 반영되어 새로운 SW가 개발되거나 주도적으로 개발하여 이용하는 경우이다.⁷¹⁾ 물론 후자도 API⁷²⁾를 개방하여, 어느 정도 오픈정책을 펴기는 하지만 실제적으로는 자신의 영역을 개방하지는 않는다는 점에서 폐쇄형 자기 혁신을 이끌어가고 있다. 이처럼 SW는 자기 혁신과 개방형 혁신이 병존하는 시스템이라고 보나, 효율성에 대해서는 시각차가 작지 않다. 특히 “컴퓨터프로그램은 독립적 혁신보다는 점진적인 혁신이 주를 이루며, 후속 혁신이 이루어지지 않을 경우 기술혁신이 정체되거나 기술 확산이 저해되어 사회적인 효율성을 저해할 우려가 높다”⁷³⁾고 한다.

SW특허의 성립성을 논함에 있어서 자연법칙을 이용한 것인지가 많은 논란이 되어왔다.⁷⁴⁾ 이에 미국 등의 경우와 같이 발명의 정의를 개정할 것을 주장하기도 한다.⁷⁵⁾ 즉, 자연

를 갖는 기술이라는 용어보다 동적인 의미를 갖는 기술변화나 기술진보 혹은 기술혁신이라는 용어가 더 적합하게 사용된다”고 한다. 설성수, 기술혁신론, 법문사, 2011, 87면.

70) “저작권은 결코 독립적으로 이루어지는 것이 아니라 누적적으로 이루어지는 경우가 많다. 컴퓨터 프로그램은 특히 이런 속성이 강하다. 이러한 저작권의 누적적 혁신의 속성은 후발저작자의 선발저작자의 권리침해의 문제보다, 선발저작자의 후발저작자의 저작활동을 저해하는 형태로 발생할 가능성을 높게 한다”고 한다. 최승재, 컴퓨터 프로그램보호와 저작권남용, IT와 법연구 제5집, 2011.2, 74면. 본 주장은 SW저작권을 염두에 둔 것이지만, 특허의 경우에도 다르지 않다.

71) “소비자들은 처음에는 혁신의 판매이익에 대한 의도를 가지지 않은 채 본인들이 실제로 사용하기 위해 창조하는 경우가 많다. 소비자들은 현재 존재하는 제품의 기능들을 변경하거나, 새로운 디자인을 제조자에게 제안하기도 하며, 아예 새로운 제품을 만들기도 한다”고 한다. Melissa A. Schilling, 김길선 역, 기술경영과 혁신전략, McGraw-Hill Korea, 2011, 26면.

72) application programming interface의 약어로, “운영체제와 응용프로그램 사이의 통신에 사용되는 언어나 메시지 형식”을 말한다. 네이버 지식백과, 2014.12.17.일 검색.

73) 최승재, 컴퓨터 프로그램보호와 저작권남용, IT와 법연구 제5집, 2011.2, 79면.

74) “자연법칙이라는 측면에 너무 치중하여 유용한 발명에 대해 특허를 부여하지 않거나, 불필요하게 하드웨어와 결합된 형태로서만 특허성을 인정하게 되면, 기술개발을 통해 산업발전에 이바지한다는 특허제도의 본래의 취지에도 부응하지 못하는 결과를 초래하게 될 것”이라는 주장이다. 김순석 외, BM 특허 보호를 위한 법제도 개선방안, 정보통신부, 2002.12, 164면.

75) 35 U.S.C. 101 Inventions patentable. Whoever invents or discovers any new and useful process,

법칙을 요건으로 하는 정의는 유연한 특허제도를 이끌어낼 수 없다는 것이다. 그러나 BM을 포함한 SW특허는 기술 내지 산업 트렌드에 민감하기 때문에 정책적으로 기술수준을 완화할 경우에는 부실�특허의 양산이 가능해진다. 분쟁 내지 무효에 대한 다툼이 급증할 수 있어 발명의 정의를 엄격하게 두고, 이를 심사 내지 사법적 판단에서 함부로 권리가 부여될 수 없도록 하는 것이 법정책적으로 타당하다고 본다.⁷⁶⁾

V. 결론

특허제도는 특허의 발명, 이용, 보호라는 세 가지 축의 균형을 통해서 그 목적을 달성할 수 있다. 그런데 지금까지는 보호를 중심으로 이루어져왔다고 해도 과언이 아니다. 소프트웨어 특허도 활용을 목적으로 하기보다는 경쟁업자의 침해를 차단하기 위한 목적으로 이루어지고 있다는 점에서 특허는 활용성은 떨어지고, 기술진보나 혁신을 목적으로 하는 특허제도의 취지와는 괴리가 발생하게 된다. 이러한 과학기술의 발전과 문화창달을 위해서 헌법은 발명가, 저작자 등의 권리를 보호토록 규정하고 있다. 즉, 헌법 제22조 제2항은 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”고 규정함으로써 과학기술자의 특별보호를 명시하고 있으나 이는 과학·기술의 자유롭고 창조적인 연구개발을 촉진하여 이론과 실제 양면에 있어서 그 연구와 소산(所産)을 보호함으로써 문화창달을 제고하려는 데 그 목적이 있는 것이며 이에 의한 하위법률로써 저작권법, 발명보호법, 특허법, 과학기술진흥법, 국가기술자력법 등이 있다.⁷⁷⁾ 따라서 방어적 특허보다는 이용을 통해서 기

machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. 미국 특허법 제101조는 특허의 대상을 방법(process), 기계(machine), 제품(manufacture) 및 조성물(composition of matter) 또는 이들의 개선물 등 크게 4가지로 제시하고 있으며, 이들은 새롭고(new) 실용적(useful)이어야한다는 조건을 명시하고 있다. 또한, 제101조에서 방법(process)은 해당 방법, 기계, 제품, 조성물 및 물질의 새로운 용도를 포함하는 것으로 정의되어 있기 때문에, 새로운 용도 발명도 특허의 대상이 된다.

76) 미국의 Pro-patent정책에 따라 1998년 이후 다양한 BM 및 SW특허가 허여되어왔으나, 엘리스 판결에서 미국 대법원은 자연법칙(laws of nature), 자연현상(natural phenomena), 추상적 아이디어(abstract ideas)는 미국 특허법 제101조에 포섭할 수 없어 특허대상이 아니라고 보았다. 즉, 동 판결에서 대법원은 “엘리스의 발명은 위 3개 중 추상적 아이디어에 해당하여 무효라고 판시하였다. Alice Corp. v. CLS Bank International 573 U. S. _ (2014). 동 판결에 대해서는 전정화 외, 영업방법발명의 성립성 판단기준, 산업재산권 제44호, 2014, 15면 이하 참조.

77) 현재 1993. 11. 25. 92헌마87, 판례집 5-2, 468 [기각].

술발전이나 문화창달에 기여할 수 있도록 해야 한다.

저작권 제도와 특허제도의 가장 큰 차이점 또는 소프트웨어 특허의 가장 큰 문제점은 타인의 특허를 모방하지 않아도 특허권 침해가 된다는 점이다. 이러한 이유로 특허가 기술 개발을 유인하는 것인지 의문이 제기된다. 따라서 기술혁신을 이끌어내기 위한 특허전략은 “기술 보호가 아닌 기술 이용”으로 정책적 방향을 수립하는 것이 필요하다.

소프트웨어의 보호 정책에서 무엇보다 중요한 것은 “컴퓨터 관련 발명의 특허법적 보호는 이론적으로나 현실적으로나 긍정 또는 부정의 이분법적 접근으로 해결될 문제가 아니라, 현재 특허법적으로 보호하고 있는 컴퓨터 관련 발명의 보호요건 특허 신규성과 진보성의 판단기준을 합리화하고 그 특허권의 남용가능성을 최소화하기 위한 해석론을 모색함으로써 해결될 문제”⁷⁸⁾라는 지적은 의미가 있다.

아울러, 컴퓨터 관련 발명의 개발자가 선의의 창작자인 경우에는 통상실시권을 허용하는 주장이 있다. 특허제도가 강력한 점은 선의의 발명자에 대해서도 동일 유사한 발명에 대해서는 특허권의 침해를 인정한다는 것이다. 그러나 특허법의 발명의 장려를 목적으로 한다는 점에서 이러한 일방적인 권리부여 방식은 합리성을 갖는다고 볼 수 없다. 물론 제도적 보완으로서 선사용권을 부여하고 있지만, 이는 제한적일 수밖에 없다. 따라서 명시적인 통상실시권을 허용하는 개정은 타당하다고 본다.⁷⁹⁾ 실제 “타인의 창작물을 도용한 사실이 없는데도 타인이 특허등록을 받은 기술과 동일하다는 이유로 불이익을 받는 것도 방지해야 한다. 따라서 선의 창작자의 통상실시권 제도를 창설하는 것은 원칙적으로 바람직한 일”⁸⁰⁾이라고 한다.

실제 선호되고 있는 오픈소스 SW 방식은 지식재산권 제도를 통한 SW보호에 대한 반발이다. SW 활용을 통해 개인, 사회, 국가의 질적인 제고를 높이는 SW중심사회에서는 독점권을 통해 SW의 이용을 제한함으로써 SW기술의 진보를 이끌어내기 는 어렵다고 본다. 결국 SW를 이용할 수 있는 환경을 마련하고, 그러한 환경에서 비즈니스 모델이나 사회적 영향력을 높여나가는 것이 SW 및 관련 산업의 진흥을 이끌어낼 것이다.

78) 정상조·박준석, 지식재산권법, 홍문사, 2013, 76면.

79) 그러나 이러한 견해에 대해 “특허법 제130조는 특허권 침해행위에 대하여 과실이 추정된다고 규정한다. 자신이 선의임을 적극적으로 입증하여 이러한 추정을 번복시킴으로써 특허권 침해행위의 책임을 벗어나는 것은 몰라도, 이러한 자에게까지 통상실시권을 허용하는 것에 대해서는 좀 더 신중한 고려가 있어야 한다”고 주장한다. 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8, 416면.

80) 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8, 416면.

■ 참고문헌

- 강홍정, 컴퓨터 소프트웨어의 특허보호에 대한 연구, LAW&TECHNOLOGY 제8권 제3호, 2012
- 구대환, 컴퓨터프로그램 기술혁신의 효과적인 보호를 위한 제언, 창작과관리, 2011
- 권영준, 특허권 남용의 법리와 그 관련 문제, 산업재산권 제36호, 2011.12
- 김관식, 컴퓨터프로그램의 특허법상 보호에 관한 특허법 제2조 개정시안의 법적 의의 및 과제, 法學研究 第23卷 第1號, 2012.6
- 김기영, 소프트웨어 특허 침해에 대한 구제, LAW&TECHNOLOGY 제3권 제4호, 2007.7
- 김순석 외, BM 특허 보호를 위한 법제도 개선방안, 정보통신부, 2002.12
- 설성수, 기술혁신론, 법문사, 2011
- 손경한 편저, 신특허법론, 법영사, 2005,
- 송상현·김문환·양창수, 컴퓨터프로그램보호법 축조연구, 서울대학교출판부, 1989
- 이상정, 컴퓨터 소프트웨어 관련 특허의 인정범위와 한계, 지적재산권법연구 제3권, 1999
- 이상정, 컴퓨터프로그램보호방법의 재검토, 서울대학교 법학 제48권 제1호, 2007
- 이인권, BM발명과 특허제도, 한국경제연구원, 2002
- 전삼현, 프로그램지적재산권 담보제도 수립을 위한 법적 연구, 프로그램심의조정위원회, 2000
- 전정화 외, 영업방법발명의 성립성 판단기준, 산업재산권 제44호, 2014
- 정상조·박준석, 지식재산권법, 홍문사, 2013
- 정상조·박성수 공편, 특허법 주해 I, 박영사, 2010
- 조영선, 특허법, 박영사, 2011
- 中山信弘 著, 한일지재권연구회 역, 특허법, 법문사, 2001
- 최승재, 컴퓨터 프로그램보호와 저작권남용, IT와 법연구 제5집, 2011.2
- 최형구, 소프트웨어의 특허법적 보호 필요성, 産業財産權 第23號, 2007.8
- 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2014
- 盛岡一夫, 著作権의 法的 性質, 著作権과 民法의 現代的 課題, 法學書院, 2003
- Final Report of the National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works, Library of Congress, 1979
- Melissa A. Schilling, 김길선 역, 기술경영과 혁신전략, McGraw-Hill Korea, 2011
- Suzanne Scotchmer, Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law, Journal of Economic Perspectives, Vol.5, No.1, 1991

Hongik Law Review, Vol. 15, No. 4(2014)

【ABSTRACT】

SW Patents lead the Technology Innovation?

Yun Myung KIM

Patent system can be through the invention of Patent, the use and the protection of the balance of the three axes to achieve its purpose. It is not an exaggeration to say that has been organized around the protection of until now. From software patents intended for use is made for the purpose of blocking the invasion of competitors. Thus, patent usability decreases, it becomes possible to generate multiplied separately from the purpose of the patent system intended for technicians innovation. Therefore, rather than a defensive patent, through the use, you need to be able to contribute to the technology advances and cultural promotion. Copyright system and or the maximum of the difference of the patent system, biggest problem of software patents, and even if they do not mimic the patent of others is the point of becoming a patent infringement. For these reasons, patents have been filed is questionable whether to attract technology development. Thus, patent strategy to elicit innovation seen as "not a protection technique, and the use of technology", it is necessary to establish the direction of the policy.

Key Words : copyright system, patent system, software, software patents, technology innovation